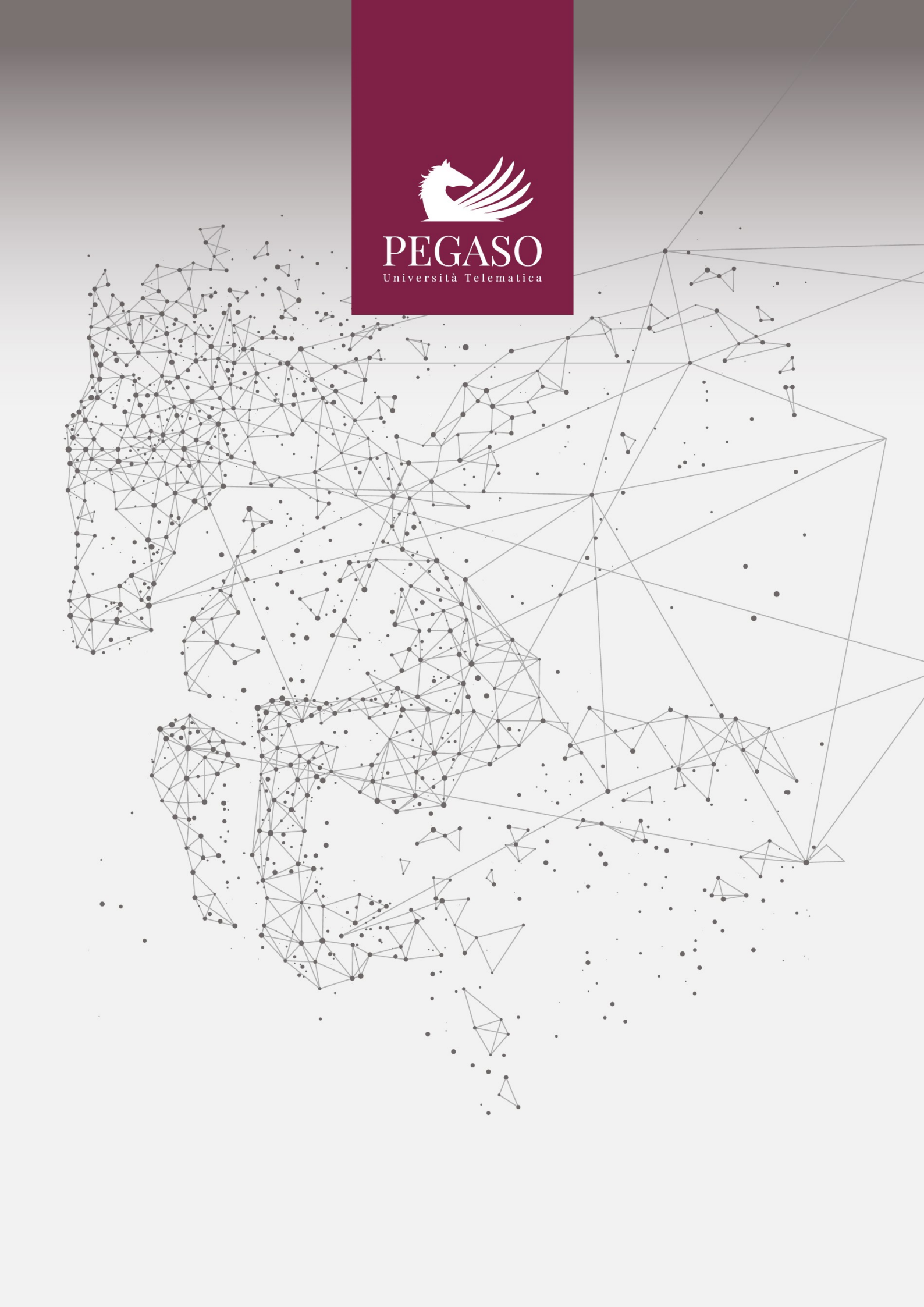

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 PROFILAZIONE 3

2 PROFILAZIONE E PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 7

3 PRIVACY E NUOVE TECNOLOGIE 13

BIBLIOGRAFIA 15

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Profilazione

La profilazione viene definita nel Regolamento UE 679/2016 (GDPR) nell'articolo 4 numero 4 come:

> *«profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica*.

Rilevante in questo senso è il considerando 30:

CONSIDERANDO 30: *Le persone fisiche possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di altro tipo, come i tag di identificazione a radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili delle persone fisiche e identificarle*.

La profilazione è un tipo di trattamento che, combinato all'enorme quantità di dati prodotti dalle persone fisiche online, sta diventando sempre più utilizzato, cosa che tuttavia comporta alcuni rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In particolare, possiamo elencare:

- Processi poco trasparenti
- Alimentazione di stereotipi
- Influenza sulla segregazione sociale.

Analizzando la definizione di profilazione che abbiamo sopra individuato, è possibile distinguere tre elementi:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Trattamento automatizzato (ma comunque non è escluso che vi sia un qualche tipo di intervento umano)
2. Effettuata su dati personali
3. Deve valutare aspetti personali relativi ad una persona fisica.

Per quanto riguarda questo ultimo aspetto, la valutazione o giudizio della persona fisica necessaria per la profilazione implica che vi sia l'individuazione di caratteristiche di comportamento della persona presenti o future, in particolare in merito a:

- Capacità di eseguire un compito
- Interessi
- Comportamento probabile.

Con riferimento alla profilazione, il Gruppo di Lavoro Articolo 29 (WP29) ha avuto modo di fornire i seguenti chiarimenti nelle "Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679" nella versione emendata e adottata in data 6 febbraio 2018:

"*La profilazione è costituita da tre elementi:*

• *deve essere una forma di trattamento automatizzato;*

• *deve essere effettuata su dati personali;*

• *il suo obiettivo deve essere quello di valutare aspetti personali relativi a una persona fisica.*

L'articolo 4, punto 4, fa riferimento a "qualsiasi forma di trattamento automatizzato" e non al trattamento "unicamente" automatizzato (di cui all'articolo 22). La profilazione deve implicare una qualche forma di trattamento automatizzato, sebbene il coinvolgimento umano non comporti necessariamente l'esclusione dell'attività dalla definizione.

La profilazione è una procedura che può implicare una serie di deduzioni statistiche. Spesso viene impiegata per effettuare previsioni su persone usando dati provenienti da varie fonti per

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

dedurre qualcosa su una persona in base alle qualità di altre persone che sembrano statisticamente simili.

Il regolamento afferma che la profilazione è il trattamento automatizzato di dati personali per valutare determinati aspetti personali, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti persone fisiche. L'uso del verbo "valutare" suggerisce che la profilazione implichi una qualche forma di valutazione o giudizio in merito a una persona.

La semplice classificazione di persone basata su caratteristiche note quali età, sesso e altezza non determina necessariamente una profilazione. Quest'ultima dipende infatti dalla finalità della classificazione.

Ad esempio, un'azienda potrebbe voler classificare i propri clienti in base all'età o al sesso per finalità statistiche e per acquisire una panoramica aggregata dei propri clienti senza effettuare previsioni o trarre conclusioni in merito a una persona specifica. In questo caso, la finalità non è la valutazione delle caratteristiche individuali e quindi non si tratta di profilazione.

Il regolamento si ispira alla definizione di profilazione di cui alla raccomandazione CM/Rec (2010)132 del Consiglio d'Europa ma non la riprende tale e quale, infatti la raccomandazione esclude il trattamento che non include la deduzione. Tuttavia, la raccomandazione spiega in maniera utile che la profilazione può comportare tre fasi distinte:

- *raccolta dei dati;*
- *analisi automatizzata per individuare correlazioni;*
- *applicazione della correlazione a una persona fisica per individuare caratteristiche di comportamento presenti o future.*

Il titolare del trattamento che effettua la profilazione dovrà assicurarsi di soddisfare le prescrizioni del regolamento in relazione a tutte le fasi di cui sopra.

In generale, la profilazione consiste nella raccolta di informazioni su una persona (o un gruppo di persone) e nella valutazione delle loro caratteristiche o dei loro modelli di

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

comportamento al fine di includerli in una determinata categoria o gruppo, in particolare per analizzare e/o fare previsioni, ad esempio, in merito a:

- *capacità di eseguire un compito;*
- *interessi, o*
- *comportamento probabile.*"

La profilazione può comportare l'utilizzo di dati personali originariamente raccolti per una finalità diversa; è necessario quindi operare una valutazione ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 4 del GDPR, che stabilisce:

> *4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:*
>
> *a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;*
>
> *b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;*
>
> *c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;*
>
> *d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;*
>
> *e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione*.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 Profilazione e processi decisionali automatizzati

Un processo decisionale automatizzato è la capacità di prendere una decisione impiegando mezzi tecnologici senza coinvolgimento umano, ricorrendo o meno alla profilazione. I due concetti, infatti, si sovrappongono solo in alcune circostanze: sarà possibile una profilazione che non comporti processo decisionale automatizzato, o un processo decisionale automatizzato che avvenga senza profilazione, ma anche un trattamento che comporti processo decisionale automatizzato sulla base di una profilazione.

Al riguardo si possono fornire i seguenti esempi:

- Profilazione: raccolta dati e sviluppo di un profilo delle persone da parte di Facebook per poi venderle a imprese che intendono migliorare l'orientamento dei loro beni e/o servizi;
- Processo decisionale automatizzato: multa per eccesso di velocità basata sulla decisione di un autovelox;
- Processo decisionale automatizzato con profilazione: multa per eccesso di velocità basato solo su prove fornite da autovelox e l'ammontare determinato sulla valutazione delle abitudini di guida della persona.

Nelle Linee guida succitate, il WP29 così si è espresso con riguardo ai processi decisionali automatizzati:

"*Il processo decisionale automatizzato ha una portata diversa da quella della profilazione, a cui può sovrapporsi parzialmente o da cui può derivare. Il processo decisionale esclusivamente automatizzato consiste nella capacità di prendere decisioni impiegando mezzi tecnologici senza coinvolgimento umano. Le decisioni automatizzate possono essere basate su qualsiasi tipo di dati, ad esempio:*

- *dati forniti direttamente dall'interessato (come le risposte a un questionario);*

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

• dati osservati riguardo a una persona (come i dati relativi all'ubicazione raccolti tramite un'applicazione);

• dati derivati o desunti, come un profilo della persona che è già stato creato (ad esempio un punteggio sull'affidabilità creditizia).

Le decisioni automatizzate possono essere prese ricorrendo o meno alla profilazione, la quale a sua volta può essere svolta senza che vengano prese decisioni automatizzate. Tuttavia, la profilazione e il processo decisionale automatizzato non sono necessariamente attività separate. Qualcosa che inizia come un semplice processo decisionale automatizzato potrebbe diventare un processo basato sulla profilazione, a seconda delle modalità di utilizzo dei dati.

Le decisioni che non sono unicamente automatizzate potrebbero includere anche la profilazione. Ad esempio, prima di concedere un mutuo, un istituto bancario può prendere in considerazione il punteggio sull'affidabilità creditizia del mutuatario, associandolo a ulteriori interventi significativi svolti da esseri umani prima che venga adottata qualsiasi decisione relativa alla persona in questione."

Ai trattamenti che comportino una profilazione o un processo decisionale basato sulla profilazione si devono applicare i principi generali del GDPR, compresa l'individuazione di una base giuridica ai sensi degli articoli 6 o 9 del GDPR. Per i trattamenti che comportino un processo decisionale basato unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, servono invece alcune garanzie supplementari, individuate dall'articolo 22 del GDPR, rubricato "Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione", che stabilisce:

> *1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.*
>
> *2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;

b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;

c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

Al riguardo, il considerando 71 del GDPR così afferma:

CONSIDERANDO 71: *"L'interessato dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto a una decisione, che possa includere una misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, quali il rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani. Tale trattamento comprende la «profilazione», che consiste in una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato, ove ciò produca effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Tuttavia, è*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

opportuno che sia consentito adottare decisioni sulla base di tale trattamento, compresa la profilazione, se ciò è espressamente previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento, anche a fini di monitoraggio e prevenzione delle frodi e dell'evasione fiscale secondo i regolamenti, le norme e le raccomandazioni delle istituzioni dell'Unione o degli organismi nazionali di vigilanza e a garanzia della sicurezza e dell'affidabilità di un servizio fornito dal titolare del trattamento, o se è necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, o se l'interessato ha espresso il proprio consenso esplicito. In ogni caso, tale trattamento dovrebbe essere subordinato a garanzie adeguate, che dovrebbero comprendere la specifica informazione all'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e di contestare la decisione. Tale misura non dovrebbe riguardare un minore. Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente nel rispetto dell'interessato, tenendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti. Il processo decisionale automatizzato e la profilazione basati su categorie particolari di dati personali dovrebbero essere consentiti solo a determinate condizioni."

Il considerando 72, invece, aggiunge:

CONSIDERANDO 72: "*La profilazione è soggetta alle norme del presente regolamento che disciplinano il trattamento dei dati personali, quali le basi giuridiche del trattamento o i principi di*

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

protezione dei dati. Il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento («comitato») dovrebbe poter emanare orientamenti in tale contesto."

Il principio generale, dunque, è che non devono essere prese decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati. Esistono, tuttavia, alcune eccezioni, come emerge dall'articolo 22 del GDPR. In questi casi, è necessario che vi siano delle misure adeguate alla tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato:

- Diritto ad essere informati
- Diritto a richiedere l'intervento umano
- Diritto a contestare la decisione.

Dato che questo tipo di trattamento comporta spesso l'utilizzo di nuove tecnologie e comporta dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, sarà necessario che il titolare effettui, preventivamente, una Valutazione d'Impatto Privacy o DPIA (Data Protection Impact Assessment).

È fondamentale, inoltre, che all'interessato sia fornita adeguata informativa in merito al trattamento; questa dovrà contenere, in particolare:

- una comunicazione all'interessato che si sta svolgendo tale tipo di attività;
- informazioni significative sulla LOGICA UTILIZZATA;
- una spiegazione dell'importanza e delle conseguenze previste di tale trattamento.

Come garanzie adeguate per questo tipo di trattamento, possono essere elencate a titolo esemplificativo:

- controlli regolari di garanzia della qualità dei sistemi;
- verifica degli algoritmi per dimostrare che stanno effettivamente funzionando come previsto e non producono risultati discriminatori, errati o ingiustificati;
- per gli algoritmi di terzi, ottenimento di garanzie contrattuali che sono stati effettuati audit e test e che l'algoritmo è conforme alle norme concordate;

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- misure specifiche per la minimizzazione dei dati al fine di prevedere periodi di conservazione chiari per i profili e per tutti i dati personali utilizzati durante la creazione o l'applicazione dei profili;
- utilizzo di tecniche di anonimizzazione o pseudonimizzazione nel contesto della profilazione;
- meccanismi di contestazione della decisione;

o un meccanismo per assicurare intervento umano.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 Privacy e nuove tecnologie

Vi sono alcuni esempi piuttosto recenti di utilizzo di nuove tecnologie dal quale sono emerse problematiche relative alla tutela della privacy delle persone fisiche.

Un primo caso è quello della giustizia predittiva, vale a dire l'utilizzo di software nell'ambito dei procedimenti giuridici, solitamente penali. Nell'Unione Europea i principi generali derivanti dalla Convenzione di Strasburgo sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (1981) e dal GDPR fanno sì che sia possibile garantire il rispetto della dignità umana anche in questi casi; la disciplina contenuta nell'articolo 22 del GDPR è un valido esempio di limite posto a tutela dei soggetti in questi contesti.

Negli Stati Uniti, invece, l'utilizzo di questi strumenti è meno controllato. Il primo caso di applicazione di un processo decisionale automatizzato in un processo in fase di cognizione è quello della Suprema Corte del Wisconsin contro Eric L. Loomis nel 2016, dove era stato utilizzato il software "Compass". In quel contesto, tuttavia, nell'applicazione della pena il software aveva ritenuto il soggetto ad alto rischio di recidiva sulla base di un numero limitato di informazioni e una base di calcolo costituita da un gruppo di individui con caratteristiche assimilabili, producendo una decisione sulla base di dati viziati, con conseguenze aberranti.

Un altro esempio di problemi relativi al trattamento dei dati personali nel contesto delle nuove tecnologie si trova nel Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 15 novembre 2018 sulla fatturazione elettronica: l'Autorità ha evidenziato che prevedere la conservazione da parte dell'Agenzia delle entrate delle fatture in formato XML (e non solo dei dati necessari ad assolvere obblighi fiscali), senza alcuna misura per assicurare la minimizzazione, limitazione delle finalità e riservatezza dei dati in esse contenuti, non appare proporzionato all'interesse pubblico perseguito con l'obbligo di fatturazione elettronica.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Infine, un caso più recente: l'utilizzo delle app di contact tracing per far fronte alla pandemia da Covid-19 ha comportato attente analisi da parte delle Autorità di protezione dei dati personali, in quanto si tratta di applicazioni particolarmente invasive se utilizzate senza le opportune garanzie. In Italia l'app "Immuni" è stata sviluppata tenendo conto delle indicazioni del Garante e dell'EDPB per proteggere la privacy degli utenti: è stato adottato un sistema decentralizzato, in base al quale il "contatto stretto" con un soggetto positivo al Covid-19 viene notificato direttamente all'utente, ed è stato configurato un funzionamento che tenga conto della tutela della privacy fin dalla progettazione (*privacy by design* e *by default*). Tale funzionamento si può schematizzare nel modo seguente:

1. Generazione casuale, mediante algoritmi crittografici, di una chiave temporanea «TEK»;
2. La TEK genera un identificativo di prossimità di un dispositivo mobile («RPI»);

Gli RPI sono ricevuti da altri dispositivi con interfaccia bluetooth.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Gruppo di Lavoro Articolo 29, Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679, versione emendata e adottata in data 6 febbraio 2018
- Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento nei confronti dell'Agenzia delle entrate sull'obbligo di fatturazione elettronica - 15 novembre 2018 [9059949]

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).